

1503224-54.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... estavam associados para a prática do tráfico.

Não foram colhidas provas seguras de que os réus se associaram, de forma ao menos estável, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tratando-se de autêntica hipótese de co-autoria.

Por todo o exposto, de rigor a procedência da ação penal tão somente em relação ao crime de tráfico e corrupção.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503224-54.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503224-54.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2349649/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 22117465 - DEL.POL.CAJAMAR, 2216/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2349649 - 01º D.P. CAJAMAR, 2216/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAINA LIMA JOAQUIM e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

THAINA LIMA JOAQUIM e LÚCIO APARECIDO DO AMARAL PEREIRA JUNIOR foram denunciados pelo Ministério Público por infração ao art. 33 e 35, "caput", da Lei 11.343/06 e 333, CP, porque, no dia 23 de dezembro de 2021, foram surpreendidos trazendo consigo e guardando a droga descrita na denúncia. Além disso, ofereceram vantagem indevida aos guardas municipais e estavam associados para a prática do tráfico. Regularmente notificados, os réus apresentaram defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

Os réus foram interrogados.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a preliminar de nulidade.

Em decisão recente, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO reconheceu a validade do flagrante efetuado pela guarda municipal, que pode ser efetuado por qualquer do povo, ao julgar apelação contra sentença proferida nesta vara:

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVESTID DEFLAGRADA POR GUARDA MUNICIPAL – AFRONTA À CARTA DA REPÚBLICA INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP – AÇÃO DEFLAGRADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSERIDA NO PODER CONSTITUCIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS EM PROL DO CIDADÃO OUTORGADA À GUARDA MUNICIPAL, NO ART. 144, § 8º, DA CF, DEPARANDO-SE CASUALMENTE COM UM CRIME PERMANENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGITIMAMENTE DEFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA. No ponto, está dentre as atribuições da Guarda Municipal o poder de fiscalizar, sempre em prol do cidadão e, se no exercício desta atribuição, deparar-se com crime permanente, no caso, o tráfico de entorpecente, há flagrante delito e a captura é lícita, ocorrendo sob a forma admitida pelo art. 301 do Código de Processo Penal, sendo lícita a investida para garantia da ordem pública e cumprimento da legislação, numa atribuição estendível a qualquer do povo. Anota-se que a proteção inserta no § 8º do art. 144 da CF, abrange segurança da sociedade, tanto da população fixa, quanto da flutuante, protegendo, resguardando, garantindo, a dignidade da pessoa humana, os direitos coletivos e individuais, sempre dentro da legalidade, desta forma servindo como molas propulsoras para garantia e manutenção da paz social. Por proteção, entende-se toda espécie de assistência ou auxílio, prestado às coisas ou às pessoas, a fim de que se resguardem contra males que lhe possam advir (SILVA, De Plácido, Vocabulário Jurídico, 4ª ed., vol. III, Forense, p. 1249). APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502012-32.2020.8.26.054) Comarca: CAJAMAR - (Processo nº 1502012-32.2020.8.26.0544) Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo A ação penal é parcialmente procedente.

Quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11343/06, impõe-se a absolvição dos réus, pois a materialidade se encontra duvidosa.

A configuração do delito em questão pressupõe associação estável e permanente, ou seja, o ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, além de vontade de associar-se distinta da vontade necessária à prática do crime visado. Neste sentido: “O apelo do Ministério Público não deve ser acolhido. O crime de associação não ficou provado, isto porque inexistente qualquer prova de estabilidade. Cuida-se, ao meu juízo, de evidente caso de co-autoria” (Apelação nº 990.09.368658-9, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

“Associação para o tráfico – Absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Inocorrência de comprovação da estabilidade da associação - Indícios insuficientes para demonstrar a prática do crime do artigo 35, 'caput', da Lei nº 11.343/2006” (Apelação nº 990.10.081911-9, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

De fato, a prova produzida nos autos não foi suficiente para comprovar que os réus estavam associados para a prática do tráfico.

Não foram colhidas provas seguras de que os réus se associaram, de forma ao menos estável, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tratando-se de autêntica hipótese de co-autoria.

Por todo o exposto, de rigor a procedência da ação penal tão somente em relação ao crime de tráfico e corrupção.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico,

nos termos da denúncia.

Ademais, a ré THAINA confessou integralmente a prática do comércio ilícito, apesar de tentar afastar a responsabilidade de LÚCIO, que, no entanto, foi flagrado pelos guardas escondendo as drogas comercializadas.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos merecem toda a credibilidade, porque não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho. Não é crível que os guardas aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, os réus, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização dos réus e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07.

O mesmo se diz em relação a corrupção, eis que os guardas foram claros ao explicar a participação de cada um no oferecimento da proposta indevida.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e K2, e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei n 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base" (Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e quantidade da droga apreendida, fixo a pena em:

- 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, para THAINA;
- 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, para LÚCIO, já que, além das circunstâncias já mencionadas, ostenta 2 CONDENAÇÕES POR ROUBO, sendo uma delas DEFINITIVA;

Para THAINA, a pena retorna ao mínimo legal, em razão da CONFISSÃO.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, que não se mostra viável, eis que LÚCIO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES (2 CONDENAÇÕES POR ROUBO, sendo uma delas DEFINITIVA) e THAINA, presa por TRÁFICO, BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A PRATICAR O MESMO CRIME EM MENOS DE 7 DIAS, tudo demonstrando ENVOLVIMENTO HABITUAL COM ATIVIDADES CRIMINOSAS.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

A minguagem de outras circunstâncias, torno as penas definitivas.

Em relação ao crime de corrupção:

- para THAINA, a pena será fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias multa;
- para LÚCIO, em razão dos maus antecedentes, com acréscimo de 1/6, em 2 anos e 4 meses e 11 dias multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- CONDENAR THAINA LIMA JOAQUIM 'a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 510 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 333 CP.
- CONDENAR LÚCIO APARECIDO DO AMARAL PEREIRA JUNIOR 'a pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 676 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 333, CP.
- ABSOLVER os réus em relação ao crime previsto no art. 35, LEI 11.343, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

O regime inicial será o FECHADO, eis que WELLINGTON ostenta maus antecedentes e TATIANE, presa por TRÁFICO, BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A PRATICAR O MESMO CRIME, tudo demonstrando ENVOLVIMENTO HABITUAL COM ATIVIDADES CRIMINOSAS, além da grande quantidade de drogas.

Portanto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 8 anos, as circunstâncias do caso concreto e a prática de CRIME HEDIONDO autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3, do Código Penal.

Neste sentido, entendimento recente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1500583-14.2020.8.26.0129, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 28 de outubro de 2022, grifo nosso):

De outro lado, a gravidade do delito é concreta, como já dito, (não sendo o caso de incidência das Súmulas 440 e 269 do STJ), em razão da quantidade e qualidade das drogas apreendidas (cocaína), que traz efeitos nefastos aos usuários, dilacerando inúmeras famílias, além da reincidência específica do réu, de modo que, mais uma vez pautado na individualização da pena, e com supedâneo na isonomia em sua aceção material, e a fim de que a Constituição, neste particular, não seja letra morta (força normativa), não há outro regime a ser imposto, senão o fechado, particularidade na qual a decisão guerreada fica mantida...

Não é apenas o montante da pena ou a gravidade abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração criminosa...

O regime fechado foi corretamente fixado, sendo o único dotado de suficiência para a repressão e a prevenção do crime de tráfico de drogas, considerando o disposto no artigo segundo, § primeiro, da Lei Federal 8072/90...

Cabe invocar ensinamento do STF: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do artigo 33 e seu parágrafo segundo, do Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º, do art. 33, com observância critérios previstos no artigo 59" (Habeas Corpus 70.289-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, RTJ 148/490).

Ainda (Apelação Criminal nº 1520430-59.2021.8.26.0228):

"o regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os mercados de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade" (TJSP, Apelação 0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, Julgado em 24/01/2017). Acrescente-se, ainda, o entendimento dessa Turma Julgadora de que "o tráfico de drogas é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis" (Relator Maurício Valala - Apelação Criminal 0004234-70.2017.8.26.0625 Julgado em 05/12/2019).

Pelos mesmos fundamentos e nos termos da decisão de fls. 427, OS RÉUS NÃO PODERÃO APELAR EM LIBERDADE.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

PI

Cajamar, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA